

1500279-13.2020.8.26.0356

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandopolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500279-13.2020.8.26.0356 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-13.2020.8.26.0356

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2059414/2020 - DEL.POL.LAVINIA, 10337516 - DEL.POL.LAVINIA, 679/19/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2059414 - DEL.POL.LAVINIA, 679/19/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2059414 - DEL.POL.LAVINIA, 679/19/105 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYANE CAROLINE ZAURISIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Vistos.

DAYANE CAROLINE ZAURISIO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 273, 1º-B, inciso V c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, 15 de dezembro de 2019, por volta das 09h00, na Penitenciária "Luiz Aparecido Fernandes", situada na Estrada Manoel Caetano, Km 03, na cidade de Lavínia, nessa Comarca de Mirandópolis, tentou distribuir e entregar a consumo de terceiros produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada, consistente em 60 (sessenta) comprimidos azuis, com a inscrição "PR",

contendo a substância sildenafil, conforme laudos periciais de fls. 16/18, 22/24 e 49/50, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, DAYANE camuflou referidos comprimidos em dois invólucros plásticos no cós de sua lingerie e dirigiu-se ao estabelecimento prisional para visitar seu companheiro, custodiado no local.

Ocorre que, durante procedimento de revista, agentes de segurança penitenciários ouviram um barulho estranho quando a denunciada se movimentava. Indagada, a denunciada retirou do cós de sua peça íntima os invólucros contendo os medicamentos de procedência ignorada.

A elevada quantidade de comprimidos (60) e sua forma de acondicionamento evidenciam que estavam destinados à distribuição e entrega ilícita no interior do estabelecimento prisional.

A denúncia recebida em 14 de setembro de 2020 (fls. 61/62).

A ré foi devidamente citada (fls. 130), e apresentou resposta à acusação (fls. 139/147). Folha de Antecedentes sem conter outros registros a (fls. 69/70).

Certidão Estadual de Distribuições Criminais contendo outros registros (fls. 75/76). Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 150/151).

Realizada audiência de instrução no dia 05 de abril de 2022. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 192/193). Prosseguiu-se com o interrogatório da ré (fls. 194/195).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, já que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito. Quanto à dosimetria da pena, afirmou que os Tribunais Superiores entendem que o preceito secundário do art. 273, §1º - B é inconstitucional e em decorrência desta inconstitucionalidade, entendem que é de rigor a aplicação do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei de Drogas e pugnou para que o Juízo observe este parâmetro na fixação da pena. Pugnou também pela aplicação da atenuante da confissão e pela causa de diminuição de pena referente à tentativa. Por fim, esclareceu que não é possível a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006 no caso; e, a Defesa técnica, por seu turno, requereu a absolvição por atipicidade de sua conduta; subsidiariamente, requereu que o delito fosse desclassificado para o inciso I, §1º - B, artigo 273 do Código Penal e que seja aplicado o efeito repristinatório com aplicação da redação antiga. Ainda, se assim não entender o Juízo, que seja aplicada a pena de acordo com o entendimento do STJ, nos termos do inciso V, §1º - B, artigo 273 do Código Penal, utilizando o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11343/2006 e a incidência do §4º deste mesmo artigo, bem como que a pena seja estipulada no mínimo legal e convertida em restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios serem sanados. A ré foi representada por Defensora e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas, por ora. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal é PROCEDENTE.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05, pelos laudos periciais de fls. 16/18, 22/24 e 49/50, bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha SANDRA CRISTINA CREMONEZ TESTI (fls. 14), agente penitenciária, declarou que na data dos fatos a ré, companheira do sentenciado Adriano Cardoso Neto, passou pelo box de revista da penitenciária, e conforme se movimentava era possível ouvir um barulho que se assemelhava ao de um embrulho. Indagou a acusada sobre a origem do barulho, e ela imediatamente retirou do cós de sua lingerie dois invólucros plásticos, contendo 60 (sessenta) comprimidos de cor azul, que supostamente eram substâncias entorpecentes. Informou que não tinha conhecimento da participação de funcionários na entrada de tais ilícitos nesta Unidade Prisional. ADRIANO CARDOSO NETO (fls. 15) declarou que estava na unidade prisional há aproximadamente 05 (cinco) meses e habitava no Pavilhão Habitacional 07, cela 07. Salientou que era companheiro da Sra. Dayane Caroline Zaurisio, ora acusada. Afirmou que não pediu para a Sra. Dayane trazer os comprimidos e não soube informar o que a motivou a trazer os comprimidos. Ainda, esclareceu que não tem conhecimento do envolvimento de servidores facilitando a entrada de objetos ilícitos para o interior da unidade.

CLÁUDIA ELENA DA PAZ (fls. 20), agente penitenciária, declarou que na data dos fatos a ré, companheira do sentenciado Adriano Cardoso Neto, passou pelo box de revista da penitenciária, e conforme se movimentava era possível ouvir um barulho que se assemelhava ao de um embrulho. Presenciou a agente penitenciária Sandra indagar a acusada sobre a origem do barulho, tendo esta imediatamente retirado do cós de sua lingerie dois invólucros plásticos, contendo 60 (sessenta) comprimidos de cor azul, que supostamente eram substâncias entorpecentes. Informou que não tinha conhecimento da participação de funcionários na entrada de tais ilícitos nesta Unidade Prisional.

A ré DAYANE CAROLINE ZAURISIO (fls. 21) declarou que é companheira do sentenciado Adriano Cardoso Neto há aproximadamente dois anos e seis meses. Afirmou que estava desempregada e estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Esclareceu que seu companheiro não sabia que ela havia trazido esses comprimidos. Informou que recebeu esses comprimidos em sua casa, de uma mulher que não conhece, na cidade de São José do Rio Preto. Salientou que não havia definido valor que receberia para trazer esses comprimidos, e que não sabe exatamente para quem ela teria que entregar esses comprimidos. Ressaltou que foi a primeira vez que havia sido flagrada com ilícitos no procedimento de revista. Por fim, afirmou que prestou a declaração sem ter sofrido qualquer tipo de coação.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha SANDRA CRISTINA CREMONESI TESTI (fls. 192), agente de segurança penitenciária, declarou que na data dos fatos a acusada dirigiu-se até a penitenciária para realizar a visita, e no momento em que realizava a revista ouviu um barulho estranho, que se assemelhava a plástico. Relatou que como visivelmente Dayane não possuía nenhuma sacola nas mãos, indagou-a sobre a origem do barulho, e a acusada prontamente entregou os comprimidos à agente penitenciária.

CLÁUDIA ELENA DA PAZ (fls. 193), agente penitenciária, declarou que na data dos fatos a funcionária Sandra ouviu um barulho estranho, que se assemelhava a um plástico, quando da revista da acusada Dayane. Relatou que a agente Sandra indagou a acusada sobre a origem do barulho, e a acusada prontamente entregou os comprimidos à agente penitenciária.

A ré DAYANE CAROLINE ZAURISIO (fls. 194/195), trabalha como doméstica, estudou, é divorciada, possui filhos e afirmou que nunca foi presa ou processada. Confessou os fatos e reiterou a veracidade de seu depoimento. Indagada sobre seus antecedentes, confirmou que já respondeu um processo de tráfico de drogas na comarca de São José do Rio Preto, e que como faz pouco tempo não sabia que já havia uma condenação. Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos.

A ré em seu interrogatório judicial confessou a prática delitiva.

A prova oral coligida em juízo também é inconteste. As testemunhas ouvidas declararam de forma firme e uníssona como surpreenderam a ré na posse dos comprimidos apreendidos. Trouxeram detalhes da conduta da acusada não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021)

Ainda, cabe pontuar que no tocante à dosimetria da pena do delito previsto no art. 273, §1º-B, inciso V c.c. artigo 14, inciso II, considerando que o preceito secundário do tipo penal aqui imputado à ré fora declarado inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 239.363/PR, este Juízo utilizará in casu, por analogia, o preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme determinação da própria Corte Especial.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. ART. 273, § 1º-B, DO CP. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. NOVA FIXAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. 1. É incabível o ajuizamento de habeas corpus em substituição ao recurso pertinente. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade suscitada nesta impetração, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma prevista no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. 3. Habeas corpus não conhecido. Expedida ordem de ofício para determinar ao Juízo das execuções que aplique o preceito secundário que melhor se adeque ao fato tipificado no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal. (HABEAS CORPUS Nº 239.363 - PR (2012/0076490-1), RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 14 de fevereiro de 2017).

De se ressaltar que o Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, de igual modo, decidiu pela a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273, do Código Penal, em razão da violação ao princípio da proporcionalidade.

Nos autos da Ação de Inconstitucionalidade nº 0052451-46.2016.8.26.0000, julgada em 28 de junho de 2017, decidiu-se que:

Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal. Conhecimento. Morte do interessado no curso da revisão criminal que não leva à sua extinção. Inteligência do art. 631 do Código de Processo Penal. Verificação da desproporcionalidade do preceito secundário do dispositivo impugnado, especialmente se comparado a delitos semelhantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da pena do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal.

E nem poderia ser diferente já que a pena prevista para o tipo é sensivelmente superior àquela prevista a delitos de mesma natureza. Assim, de rigor a aplicação de pena (preceito secundário) adequado e razoável, conforme a conduta comprovadamente praticada.

Destaque-se ainda que em decisão recente o Supremo Tribunal Federal reconheceu, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, do

Código Penal à hipótese prevista no seu §1º-B, inciso I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para tal situação específica, entendeu ficar repristinado o preceito secundário do art. 273, do Código Penal, na sua redação originária: (...) 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. (STF, RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, J: 24/03/2021, DJe: 14/06/2021)

Entretanto, se observa que a decisão não se aplica a todas as outras condutas e circunstâncias possíveis de modo a, indistintamente, repristinar o preceito secundário do artigo 273 na redação originária reclusão de um a três anos e multa, em geral, mas tão somente à conduta de importar medicamento sem registro. Para as demais, aplica-se, de forma analógica, as previstas para o tráfico de drogas. Considerando que a conduta aqui imputada envolve o delito previsto no artigo 273, § 1º B, inciso V, e ainda, que muito mais se aproxima do delito de tráfico, de rigor a aplicação analógica do preceito secundário previsto para o crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, com todas suas nuances.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 273, §1º-B, inciso V c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação da ré medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à acusada, pois é primária e de bons antecedentes (Certidão de fls. 75/76), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante proveniente da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do Código Penal), contudo, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atendimento à Súmula nº 231, do STJ.

Por fim, na terceira fase incide a causa de diminuição genérica da tentativa e, considerando o iter criminis percorrido, aplico a redução no patamar mínimo de 1/3, nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, passando a pena a ser de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Deixo de aplicar o §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, visto que em um curto lapso de tempo a ré praticou outro delito, agora de tráfico de drogas (Autos nº 1500976-53.2020.8.26.0576 - o qual já há prolação de sentença condenatória, contudo ainda pendente o seu trânsito em julgado), o que denota que se dedica às atividades criminosas, não fazendo jus a esta causa de diminuição.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime ABERTO, a teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, considerando que a ré preenche os requisitos previstos no artigo 44 do

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista.

Em caso de descumprimento, a ré descontará a sanção no regime já determinado.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR DAYANE CAROLINE ZAURISIO, devidamente qualificada, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pelo valor mínimo, por infração ao artigo 273, §1º-B, inciso V c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista, ALÉM DO PAGAMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica da ré.

Determino a destruição dos comprimidos apreendidos, guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, expeça-se certidão à patrona dativa, pelo máximo da tabela, bem como intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA